

1500543-94.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... si só, não afasta a tipificação do crime de tráfico. Aliás, atualmente, os traficantes vêm utilizando desse modo de agir (distribuição de pequenas porções entre vários entregadores), a fim de dificultar a apreensão da droga e a caracterização do crime de tráfico.

Quanto ao dinheiro apreendido, o acusado não fez qualquer prova sobre a sua procedência lícita e, diante da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500543-94.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500543-94.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2096665/2022 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 24168236 -

DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 2096665 - 01º D.P. BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDJAN MACIEL PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº. 1500543-94.2022.8.26.0603 (Controle nº 811/2022).

VISTOS.

EDJAN MACIEL PEREIRA, qualificado nos autos, foi preso em flagrante, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, no dia 7

de abril de 2022, por volta das 20h20, à Rua Bahia, nº 1783, Jardim São Genaro, nesta cidade e comarca de Birigui, agindo em coautoria com o adolescente Vitor Gabriel Conrado Lopes, transportava, para fins de tráfico, 30,93 gramas de cocaína e 58,26 gramas de crack, conforme laudos de constatação às fls. 22/27 e laudos de exame toxicológicos de fls. 65/70.

Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, EDJAN MACIEL PEREIRA corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente Vitor Gabriel Conrado Lopes, com ele praticando a infração penal acima descrita.

Recebida a denúncia em 11 de maio de 2022 (fls. 91/92), o réu foi regularmente citado (fl. 104) e apresentou sua defesa escrita às fls. 111/124.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos de 01 (uma) testemunha arrolada pela acusação e 02 (duas) testemunhas arroladas pela defesa, sobrevivendo, ao final, o interrogatório do réu (fls. 197/198).

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a improcedência da ação, com a absolvição do acusado (fls. 207/211).

Por sua vez, a defesa pediu a absolvição do acusado, alegando a ausência de provas. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado e da participação de menor importância; e o direito de o réu recorrer em liberdade (fls. 214/219).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar os delitos de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06) e de corrupção de menores (art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso material (artigo 69, caput, do Código Penal).

A ação penal é parcialmente procedente, respeitado o entendimento exposto pela acusação e defesa em suas alegações finais.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e as autorias dos fatos narrados na denúncia ficaram parcialmente comprovadas.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante de fls. 01/02; a nota de culpa de fl. 10; o boletim de ocorrência de fls. 18/21; o auto de exibição e apreensão encartado às fls. 73/74; os laudos toxicológicos acostados às fls. 65/70; o relatório policial de fls. 76/79; os depoimentos das testemunhas; e as indigestas negativas apresentadas pelo acusado em ambas as fases da persecução penal.

O acusado, ouvido na delegacia, disse que tinha que vir para Birigui para receber de algumas pessoas, referente à venda de quiabos, aproveitou e ofereceu carona para o menor Vitor e pediu R\$ 50,00 para trazê-lo até Birigui. Tinha conhecimento que o menor Vitor iria comprar drogas em Birigui para vender em Piacatu. Já tinha conhecimento que o menor Vitor vendia drogas na casa dele, pois é vizinho seu vizinho. Em Birigui, levou o menor Vitor a um posto de combustível e, enquanto abastecia, Vitor se afastou e não sabe onde ele foi. Afirmou que não chegou a receber de ninguém os valores da venda de quiabos. Quando estavam indo embora, foram abordados por policiais militares. Nada de ilícito foi encontrado consigo, porém, com o menor Vitor, os policiais localizaram porções de drogas. Disse que não tentou fugir dos policiais. Afirmou que já comprou drogas de Vitor e que não vende drogas e que nunca vendeu. Foi primeira vez que Vitor veio para Birigui com ele (fls. 08/09).

Em juízo, continuou a negar a prática de tráfico de drogas. Disse que ofereceu a carona, perguntou ao Vitor se buscava drogas e ele afirmou que não, só iria levar um dinheiro e confiou nele. Negou ter confessado aos policiais que veio a birigui para comprar drogas para revender em Piacatu. O dinheiro apreendido era o troco dos R\$ 50,00 cobrados pela carona de Vitor, que utilizou para abastecer a motoneta.

Disse que não conhecia Vitor, apenas o padrasto dele, razão pela qual ofereceu a carona. Afirmou que assinou sem ler seu interrogatório na delegacia (fls. 197/198).

Como se vê, o acusado apresentou contradições em seus interrogatórios.

Inicialmente, na delegacia, disse que sabia que o menor Vitor estava indo buscar drogas para revender na cidade de Piacatu, e que já o conhecia e tinha, inclusive,

comprado droga dele. Já em juízo, disse que não sabia de tal fato e que assinou seu interrogatório sem ler, afirmando ainda que sequer conhecia Vitor, mas somente o padrasto dele.

Diante dessas contradições, relacionadas a ponto de fundamental relevância para o deslinde da causa, não há como se dar credibilidade às versões apresentadas pelo acusado, que estão totalmente contrárias às provas coligidas nos autos e isoladas de todo o conjunto probatório, tendo sido contrariadas por provas que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado, não passando de mero expediente utilizado na tentativa de se furtar da responsabilização penal por condutas efetivamente praticadas.

Inicialmente, não prospera a afirmação do acusado de que teria assinado seu interrogatório na delegacia sem ler, porque prestou declarações perante a Autoridade Policial que presidiu a elaboração do flagrante, como se observa do documento de fl. 60/61. Ademais, o acusado, naquela ocasião, não relatou qualquer pressão para que assim o fizesse.

Os demais elementos de prova colhidos na instrução comprovaram a imputada dirigida ao acusado na denúncia.

Ademais, a versão do réu de que veio a cidade de Birigui somente para realizar cobranças não pode ser acolhida, pois se trata de alegação isolada e desprovida de elementos probatórios. Aliás, o réu sequer arrolou como testemunhas seus clientes, onde supostamente passou para realizar as cobranças, providência essa que seria de fácil consecução, caso fosse verdadeira a narrativa apresentada.

De outra parte, a testemunha André Ricardo Baptista, policial militar, ouvido em ambas as fases da persecução penal, relatou que avistou dois indivíduos em uma motocicleta, que tentou empreender fuga ao avistar a viatura, porém, foram abordados. Em revista pessoal, com o acusado Edjan foi encontrada a quantia de R\$ 9,00 (nove reais) em dinheiro e um aparelho celular. Com o menor Victor, foram encontrados 30,93 (trinta gramas e noventa e três centigramas) de cocaína e a quantia de R\$ 179,00 (cento e setenta e nove reais). Indagado, o acusado assumiu que vieram para Birigui para comprar a droga, e juntos, fracionariam a droga para revenderem na cidade de Piacatu por R\$ 10,00 (dez reais) cada porção e dividiriam o lucro. O adolescente disse que já era a quarta ou quinta vez que vinha a Birigui para comprar entorpecentes e revender em Piacatu, e que havia pagado R\$ 1.500,00 pelas porções que estavam em sua posse (fls. 05 e 197/198).

No mesmo sentido, foi o depoimento do policial militar Leandro Lima da Cruz, ouvido na delegacia (fls. 06).

Como se viu, os policiais militares confirmaram que o acusado e o menor Vitor confessaram, informalmente, que ambos vieram a Birigui para comprarem drogas e revenderem.

É cediço que o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Tal depoimento somente não terá valor quando se evidenciar o interesse do servidor na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Já o menor Vitor Gabriel Conrado Lopes, ouvido na delegacia, preferiu manter-se em silêncio acerca dos fatos (fls. 07).

Quando foi ouvido na Vara da Infância e Juventude, Vitor Gabriel assumiu a propriedade dos entorpecentes, confessou que veio a Birigui comprar drogas e disse que traficava para sustentar seu vício, conforme prova documental juntada às fls. 201/203.

Todavia, esses elementos relacionados ao depoimento do menor Vitor não são suficientes para afastar a prova colhida em juízo, sob o crivo do contraditório. Os policiais confirmaram na fase judicial que tanto o réu quanto o menor Vitor confessaram a eles que vieram juntos comprar droga em Birigui para revender na cidade de Piacatu. Afora isso, a defesa sequer arrolou o menor Vitor para ser

ouvido em juízo, dar sua versão dos fatos e confirmar seu depoimento apontado na prova documental de fls. 201/203, providência essa que seria de fácil consecução, tratando-se de ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu a contento. Por fim, as testemunhas de defesa, Carlos Eduardo Vitorino da Silva e Marcelo Evandro Bueno de Oliveira, ouvidas somente em juízo, não presenciaram os fatos, apenas teceram comentários sobre acusado e que tinham conhecimento de que ele era usuário de drogas e lutava contra o vício (fls. 197/198)

No que se refere aos entorpecentes, a perícia apontou que consiste realmente em "cocaína" (exame químico-toxicológico de fls. 65/70).

De outra parte, o entorpecente apreendido, ou seja, 30,93 gramas de cocaína e 58,26 gramas de crack; as circunstâncias da abordagem do réu (tentou fugir ao avistar os policiais militares); apreensão de celulares e dinheiro; e a confissão do réu aos policiais militares, estão a caracterizar a traficância.

Relevante apontar que não é necessário se provar qualquer ato de comércio, bastando que o agente transporte para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. Lembre-se de que o réu foi denunciado porque transportava entorpecentes, em coautoria com o adolescente Vitor.

O simples de fato de a droga não ter sido apreendida em grande quantidade, por si só, não afasta a tipificação do crime de tráfico. Aliás, atualmente, os traficantes vêm utilizando desse modo de agir (distribuição de pequenas porções entre vários entregadores), a fim de dificultar a apreensão da droga e a caracterização do crime de tráfico.

Quanto ao dinheiro apreendido, o acusado não fez qualquer prova sobre a sua procedência lícita e, diante da prova acima analisada, não há como se deixar de reconhecer que é produto do tráfico de entorpecentes.

Assim, além da robusta prova acima analisada, há indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios. A prova coletada nos autos é substancial e convincente, ficando evidente a autoria do crime por parte do réu, no crime ora apurado.

Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia, o acusado transportava 58,26g (cinquenta e oito gramas e vinte e seis centigramas) de crack e 30,93 (trinta gramas e noventa e três centigramas) de cocaína, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega a consumo de terceiros.

Quanto ao crime de corrupção de menores, não obstante a sua capitulação na denúncia, não há como ser admitida, porque tal fato será utilizado, no caso, para se configurar a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

É certo que a prática do tráfico envolveu um menor, em coautoria com o acusado, o que se tornou corriqueiro no mundo do tráfico, em razão da condição de inimizabilidade a que os mesmos estão submetidos, sujeitos que estão ao Estatuto da Criança e Adolescente, cujas condutas não são, como é cediço, punidas com o mesmo rigor da lei penal.

Deste modo, embora a denúncia não tenha apontado essa capitulação jurídica, o certo é que, de uma forma ou de outra, os próprios fatos mostram-se suficientes para que o artigo 244-B do ECA seja absorvido pelo artigo 40, inciso IV da Lei de Drogas, servindo como causa de aumento de pena para o artigo 33 do mesmo Diploma Legal, isso porque o réu se defende dos fatos, não da capitulação dada pelo órgão acusador.

Logo, as condutas encontram tipicidade na exata correspondência com o delito

definido no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, da Lei nº. 11.343/06. Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, exclua a culpabilidade do denunciado ou extinga a punibilidade. Neste ponto, embora o réu tenha alegado que era usuário de drogas, ainda que se demonstrasse tal fato, isso, por si só, não lhes impede de exercer a traficância. Muito pelo contrário, há grande afinidade entre uma e outra conduta. Se o réu é viciado há um bom tempo, isso facilita o ingresso no submundo do crime, principalmente no mercado de substâncias tóxicas. Diante desse quadro, a condição de ser o agente usuário de drogas não exclui a possibilidade de ser condenado como traficante, porque são situações que não se excluem.

Ademais, a defesa, em um primeiro momento, pediu a realização do exame químico-toxicológico (fls. 111/124), mas depois, dele desistiu antes de sua realização, o que foi homologado por este Juízo (fls. 197/198), lembrando que o réu sequer assumiu a propriedade do entorpecente.

Reconheço, pois, a ocorrência do delito, e passo a aplicar a pena.

O acusado não ostenta Maus antecedentes e as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal não lhes são desfavoráveis, o que autoriza a fixação da pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, vislumbro a existência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Ainda nesta fase, estão preenchidos os requisitos do artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, haja vista que o réu é primário, não consta possuir Maus antecedentes, além do que não há provas dando conta de que o réu se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Portanto, reduzo as penas em 1/3 (um terço), resultando em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, a qual torno definitiva.

Diante da gravidade da conduta, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12 (art. 2º, que acrescentou o § 2º ao art. 387 do CPP), a pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, obrigatoriamente, pois se trata de crime equiparado a hediondo, conforme estatuído no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.

Neste ponto, anoto que a imposição coletiva vinculante quanto à vedação de fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena imposta aos condenados pelo crime de tráfico na modalidade privilegiada, determinada pelo voto monocrático do E. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz (6ª Turma do C. STJ) em sede de HC nº 596.603/SP, foi cassada pela r. decisão exarada pelo Exmo. Ministro do C. STF, Alexandre de Moraes, no julgamento do RE nº 1.344.374, em 01/12/2021, conferindo ao julgador a liberdade de avaliar o regime prisional cabível em cada caso.

Ademais, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária do acusado, isto é, se não registra outras condenações ou prisões processuais, nem quanto ao seu comportamento e conduta no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas.

O acusado deverá continuar a responder preso por este processo, pois assim permaneceu durante a instrução e ainda estão presentes os requisitos da custódia cautelar, como se verá doravante.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, ante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR EDJAN MACIEL PEREIRA, qualificados nos autos, ao cumprimento das penas de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado (art. 2º,

§1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação da Lei nº 11.464/07) e pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, no valor mínimo unitário (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Consigno que o acusado ficou preso cautelarmente desde 08/04/2022 até a presente data, período sobre o qual fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restante da pena, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detração penal).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender incabível tal providência.

Não obstante o julgamento do Habeas Corpus n. 97.256, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu por inconstitucional a vedação à substituição por penas restritivas de direitos para o crime de tráfico, por afronta ao princípio da individualização da pena, até então não se trata de decisão proferida com efeito erga omnes.

Foi editada a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, que, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que vedava de forma abstrata (sem análise do caso concreto) a conversão em penas restritivas de direito, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo em decisão no Habeas Corpus já mencionado acima.

Com a mencionada Resolução, não se pode mais afirmar que o efeito do julgamento daquele habeas corpus não é para todos. Entretanto, a intenção do Supremo Tribunal Federal, ao decidir desta forma, e o Senado Federal, ao editar a resolução, foi somente deixar à prudente análise do magistrado do caso concreto se o réu tem ou não direito a ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e não que essa substituição seja admitida em qualquer caso de tráfico de drogas, indistintamente. Pensar assim seria um contrassenso.

Confira, neste sentido, decisão proferida em Apelação Criminal que analisou sentença proferida por este juízo:

"... Inviável, nesse passo, a pretendida substituição carcerária por restritivas de direito, porque, embora o teor da recente Resolução nº. 5/2012 do Senado Federal, fundada na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Habeas Corpus, nº. 97.256/RS – mencionado nas razões recursais –, em controle difuso de constitucionalidade, in casu, permanece impossível, data vênua, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, ou mesmo a concessão de sursis, pois o crime de tráfico de entorpecentes revela a gravidade peculiar que desestabiliza a vida em sociedade e fere de morte a saúde pública, pois enquanto fomenta, simultânea e irremediavelmente – até as pedras estão cansadas de saber –, a violência, a destruição de lares e das famílias e a prática de n crimes, sobretudo para o fim de viabilizá-lo, tanto assim que, por força de norma constitucional, é assemelhado aos delitos hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a suspensão condicional da pena, de modo que não se consegue compreender ou avaliar, por mais que se esforce, qual seria a pena substitutiva ou as condições do sursis adequadas ao traficante, emergindo sintomático que – até o momento – jurista sério algum tenha ousado sugeri-las..." (TJ-SP, Apelação Criminal nº 0009435-15.2010.8.26.0077, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Juvenal Duarte, j. 19.04.2012).

Ainda no mesmo sentido, confira julgamento proferido em processo que tramitou por essa comarca de Birigui:

"Também não faz jus a apelante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

direitos aos condenados a tráfico de drogas é incompatível com a gravidade e as circunstâncias em que o crime é cometido, não havendo qualquer tipo de violação ao princípio da individualização da pena.

Este entendimento deve prevalecer, notadamente ao se considerar a vedação expressa trazida pelo artigo 44 da Lei de Drogas.

Com efeito, o benefício consistente na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem por objetivo primordial o de possibilitar a ressocialização de indivíduos de baixa periculosidade, que praticaram delitos de pequeno grau de lesividade social.

Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de pequeno, médio ou grande porte, não tem o perfil de iniciar o cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor, as quais virão a repercutir a toda a coletividade.

Ressalta-se que uma das exigências previstas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a de que os motivos e as circunstâncias indiquem como suficiente tal medida, para a repressão do agente da conduta delituosa.

Conforme já fundamentado, tal benefício não se coaduna com as graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causa, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental, mas também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

Muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do "Habeas Corpus" nº 97256/RS, tenha expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, é de se ressaltar que tal decisão não possui o erga omnis.

E mesmo a resolução nº 5 do Senado Federal, de 15 de fevereiro de 2012, que suspendeu a eficácia da referida expressão, não acarreta direito subjetivo do agente que praticou o grave delito do tráfico de entorpecentes a tal conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Frise-se, ainda, que o artigo 44 da Lei de Drogas mantém tal vedação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput. Considerando que o § 4º é tão somente uma causa de diminuição do delito previsto no caput - e não um crime autônomo -, é possível concluir que a vedação a ele também se aplica.

Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci que "(...) o fato de haver sido prevista uma causa de diminuição de pena para o traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações criminosas, não afasta a tipificação da sua conduta como incursas no artigo 33, caput e § 1º, que são consideradas similares a infrações penais hediondas, como se pode observar pelas proibições enumeradas no artigo 44 da Lei 11343/06. Salienta-se, ademais, o cuidado legislativo em vedar a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, típica opção de política criminal para o tráfico ilícito de drogas. Não se pode criar uma nova infração penal, a partir da mera aplicação de causa de diminuição de pena. Por isso, o tráfico ilícito de drogas será sempre considerado equiparado a hediondo, ainda que comporte, por opção legislativa, pena mais branda, quando os requisitos do § 4º estiverem presentes" (in "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas", 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p.372).

Desta forma, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau" (Apelação Criminal nº 0002364-20.2014.8.26.0077. Rel. Toloza Neto).

O acusado deverá continuar a responder preso por este processo, pois sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 33/34), ocasião em que foram expostos os fundamentos necessários para a custódia cautelar, os quais ficam aqui reiterados, como razão de decidir, assim como aqueles expostos às fls. 166/167, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Ademais, continuam presentes os requisitos que recomendam a custódia cautelar do

acusado, mormente porque praticou delito equiparado aos hediondos. Nesse aspecto, a ordem pública merece resguardo.

Outrossim, seria uma verdadeira contradição que tivesse sido mantido preso durante toda a instrução e agora, condenado, viesse a recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, com fundamento nos artigos 59 da Lei nº 11.343/06, c.c. o § 4º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, acrescentado pela Lei nº 11.464/07.

Em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, após 85 (oitenta e cinco) dias contados da publicação da sentença, tornem os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila "acompanhamento de prisão preventiva".

A incineração da droga já foi determinada e realizada (fls. 164/165), nada mais havendo a ser decidido a respeito.

Com fundamento nos artigos 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e 63 da Lei nº. 11.343/06, decreto o perdimento, por serem instrumentos e produtos do tráfico de entorpecentes praticado pelo acusado, da motocicleta e do dinheiro (R\$ 9,00) apreendidos às fls. 73/74.

Quanto ao celular apreendido (fls. 73/74), apesar de ser instrumento do tráfico de drogas praticado pelo acusado, diante da natureza do objeto, entendo não ser caso de perda em favor do Senad, mas sim destruição, a qual fica desde já determinada, devendo ser realizada somente após o trânsito em julgado, expedindo-se o necessário e comunicando-se a Sala de Armas e Objetos Apreendidos.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o "Senad" quanto ao perdimento supra determinado, instruindo o ofício com cópias do auto de exibição e apreensão, da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Oficie-se também à Delegacia de Polícia de origem, informando sobre o perdimento e a destruição do aparelho celular, instruindo-se o ofício com as cópias mencionadas no parágrafo anterior.

Por fim, o tocante ao valor apreendido, referente ao menor infrator, Vitor Gabriel Conrado Lopes, no importe de R\$ 179,00 (cento e setenta e nove reais), houve instauração de processo para apuração de ato infracional, feito n. 1500727-76.2022.8.26.0077 (2ª. Vara Criminal local), razão pela qual deverá haver a desvinculação desse valor deste processo e transferido para o mencionado processo da 2ª Vara Criminal local.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para a parte.

Custas, na forma da lei.

P. R. I.

Birigui, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA